

1521874-16.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... do intento deletério de cometerem os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não se pode olvidar também que os averiguados descumpriram orientações do Ministério da Saúde de isolamento social, o qual está sendo amplamente divulgado nos meios de comunicação. Assim, as condutas dos autuados revestem-se de maior gravidade, eis que aumentaram os índices de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1521874-16.2020.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1521874-16.2020.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAMANTHA DE MELO CAUMO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

SAMANTHA DE MELO CAUMO, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no art. 171, "caput" do Código Penal, porque, segundo a apurado, no dia 03 de junho de 2020, em horário incerto, em período de calamidade pública (Decreto Estadual 64.879, de 20/03/2020), em local incerto, mas nesta cidade e comarca, concorreu na obtenção de vantagem ilícita de R\$ 44.562,50, mediante emprego de meio fraudulento, com a indução e manutenção em erro da vítima Luiz V.M.

A vítima ao ser ouvida em sede policial ofertou representação contra a ré. (fls. 25).

A denúncia foi recebida, a ré foi citada e notificada e apresentou resposta à acusação.

A ré não confessou os fatos, e por isso não lhe foi proposto o acordo de não persecução penal, previsto no art. 28- A, do Código de Processo Penal. Também não aceitou a proposta de suspensão condicional do processo alegando, em suma que não tinha meios para cumprir uma das condições impostas, qual seja a de ressarcimento da vítima.

Diante disso, mantido o recebimento da denúncia, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento durante a qual foi ouvida a vítima e em seguida a ré foi interrogada.

Assim, encerrada a instrução, a acusação requereu condenação da ré nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, postulou pela absolvição da ré, por atipicidade da conduta, com fulcro nos art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Em caso de eventual condenação pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, substituição da

pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, fixação de regime aberto para eventual início de cumprimento de pena, afastamento do reparação do dano e concessão da gratuidade da justiça com isenção do dias-multa e das custas processuais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Sem dúvida que a absolvição da acusada à vista da prova existente nos autos é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia restaram ao longo da instrução devidamente comprovados.

A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência juntado aos autos, pelo comprovante de depósito juntado a fls. 05, efetuado na conta corrente da ré, e carta de arremate de fls. 10/11, fotos do veículo e pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria também é inconteste.

De fato, ficou comprovado nos autos que a ré Samantha concorreu para o crime de estelionato e recebeu em sua conta corrente valores oriundos de atividade ilícita, decorrente de uma compra e venda não realizada, em desfavor da vítima Luiz.

Tais fatos foram devidamente esclarecidos pela vítima que ouvida em juízo afirmou que após entabular várias tratativas e enfim comprar um veículo em um site de leilão, depositou o valor do veículo na conta corrente de titularidade da ré e não recebeu o bem, ou mesmo conseguiu entrar novamente em contato com os vendedores do veículo.

A própria ré, em seu interrogatório em juízo, sequer negou ter recebido o valor em sua conta corrente. Disse, contudo, que conhecia uma vizinha de nome Poliana e lhe emprestou o cartão de sua conta corrente que somente lhe foi devolvido após uma semana e que acredita que a tal vizinha tenha feito toda a negociação com a vítima, e após ter recebido o dinheiro, fez o saque do valor e após se apoderar de todo o dinheiro, lhe devolveu o cartão bancário.

Disse ainda, que somente tomou conhecimento dos fatos ao ser chamada na delegacia de polícia para depor, e que tentou de toda forma entrar em contato com Poliana para entender a situação, mas que sua vizinha desapareceu de onde morava e nunca mais foi por ela encontrada.

Em sede policial, praticamente repetiu a mesma versão, afirmando, contudo que seu ex-companheiro também usava se cartão bancário para fazer compras na padaria e no mercado.

Estas são as provas colhidas nos autos e diante delas, outra solução não há que a condenação da ré, por sua participação no delito narrado na denúncia.

Isso, porque, a alegação da ré de que teria emprestado sua conta para terceira pessoa que desconhece o paradeiro, ou mesmo qualquer qualificação é incrível e não veio comprovada nos autos, ainda mais porque, o contrato juntado nos autos faz menção a seu nome, conta corrente e todas as demais qualificações.

Nesse ponto, ao contrário do alegado pela combativa Defesa, a tese de Defesa deve ser sim, provada nos autos, não bastando a mera alegação da ré, como quer fazer crer o combativo defensor, nos exatos termos do que dispõe o art. 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual: "A prova da alegação incumbirá a quem a fizer..."

Neste sentido: "A comprovação de álibi para fulcrar a tese de negativa de autoria é ônus da defesa, nos moldes do art. 156, do CPP, de sorte que esta não fundamenta sua assertiva por meio de quaisquer elementos, limitando-se a meras alegações, faz derruir a versão apresentada" (Ap. Crim. 2009.004387-0-SC, 2ª C., rel. Salete Silva Sommariva, 22.04.2010, v.U).

Veja-se, ademais que a participação da ré, ao fornecer o número de sua conta onde o depósito do valor da venda fraudulenta foi realizado, foi decisiva para que o crime se consumasse.

Dessa forma, considerando-se que a ré não produziu prova alguma capaz de infirmar os fatos que lhe são atribuídos na denúncia merece total acolhimento a pretensão punitiva.

Caracterizada a infração penal, passo a dosar a pena.

A ré é primária e não possui antecedentes criminais, portanto, à míngua de provas contundentes lhe favorecem todas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código

penal, e a pena base deve ser mantida em seu mínimo legal, qual seja, 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, deve-se considerar que o crime foi cometido em situação de calamidade pública tendo em vista a pandemia que assola o país por conta do coronavírus - COVID-19, reconhecida por meio do Decreto nº 64.879/2020 de 20/03/2020.

Neste ponto, respeitadas as posições em contrário, para esta magistrada, estado de calamidade pública acabou por facilitar a execução de crimes, ainda mais diante da necessidade de isolamento social a fim de retardar a propagação da doença, o que gerou a redução de pessoas e policiais nas ruas, defasando a vigilância estatal. Desse modo, a pena deve ser agravada em 1/6, chegando-se ao patamar de 01 ano e 02 meses e 11 dias-multa.

Neste sentido, já se manifestaram nossos Tribunais:

"Na segunda fase, o crime foi praticado durante o período de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19, nos termos do Decreto Estadual nº 64.879/20. Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos" (TJ-SP - PR: 15078616020208260228 SP 1507861- 60.2020.8.26.0228, Relator: Tetsuzo Namba, Data de Julgamento: 21/07/2020, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/07/2020).

E ainda: "(...) Por outro lado, cabível a manutenção da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do CP. Ora, o acusado praticou o presente crime durante período de calamidade pública (pandemia), instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento, mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença. De se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência" (Apelação Criminal 1509419- 67.2020.8.26.0228. Rel. Edison Brandão. Quarta Câmara de Direito Criminal TJSP. J. 26/01/2021).

"Não há que se falar em afastamento da agravante relativa ao cometimento do crime durante estado de calamidade pública. Isso porque trata-se de circunstância de caráter objetivo, bastando que o crime ocorra durante aquele estado emergencial, não havendo exigência legal da presença de outros requisitos para a sua configuração. Com efeito, é de notório conhecimento o reconhecimento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 até 31 de dezembro de 2020, conforme Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020. Assim, qualquer indivíduo que cometa crimes no período compreendido no citado decreto, como no caso em comento, terá sua pena agravada, haja vista que o agente se vale de uma situação dramática pela qual passa o país para delinquir. Irrelevante, ainda, que não seja o criminoso o provocador da situação excepcional; o que prevalece é sua atitude de se valer das facilidades que dela decorrem, in casu, o isolamento social, com diminuição do policiamento, por exemplo. Sobreleva registrar, outrossim, que as calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento de crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. A calamidade produz situação de incapacidade, total ou parcial, de defesa por parte da sociedade, e a exigência de abstenção da conduta é maior do que no caso de não concorrerem tais circunstâncias." (TJSP, Apelação Criminal nº 1512914-22.2020.8.26.0228, Rel. Des. Camilo Léllis, 4ª Câmara Criminal, j. 09/0).

A 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo Autos nº 1509419-67.2020: "O acusado praticou o presente crime durante período de calamidade pública (pandemia), instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na

data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença”, escreveu o magistrado em seu voto. “De se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência.”

“O Decreto Legislativo nº 06/2020, do Congresso Nacional, e o Decreto Estadual nº 64.879/2020, reconheceram a situação de calamidade pública resultante da pandemia concernente ao novo coronavírus. E o reconhecimento de tal circunstância motiva a incidência de referida agravante.

Ora, diante de tal situação de calamidade pública, a população foi orientada e, em algumas cidades, forçada, a fechar-se em casa. Vários estabelecimentos comerciais foram obrigados a cerrar portas. Esforços financeiros e humanos foram dirigidos pelo Estado ao combate à pandemia.

Desse modo, toda a sociedade foi atingida e sofreu as consequências de referida pandemia, a qual foi reconhecida como calamidade. É indiscutível que o cometimento de qualquer crime durante tal circunstância encontra maior facilidade e superior reprovabilidade, fazendo jus à respectiva exacerbação da reprimenda.

Pese tenha inteligência no sentido de emprestar uma interpretação mais restritiva para a norma prevista no artigo 61, inciso II, “j”, do Código Penal, a Câmara assentou entendimento pela incidência da circunstância agravante numa situação como a dos autos.

A compreensão é de, com o estado de calamidade provocado pela ação do coronavírus (declarado pelo Decreto Legislativo 06/2020, do Congresso Nacional), “a população foi orientada e, em algumas cidades, forçada a ficar em casa. Vários estabelecimentos comerciais foram obrigados a fechar. Esforços financeiros e humanos foram dirigidos pelo Estado ao combate da pandemia.

Desse modo toda a sociedade foi atingida e sofreu as consequências de referida pandemia, a qual foi reconhecida com calamidade. É indiscutível que o cometimento de qualquer crime durante tal circunstância encontra maior facilidade e superior reprovabilidade, fazendo jus à respectiva exacerbação da reprimenda” (Apelação nº 1512223-08.2020.8.26.0228, rel. Des. Hermann Herschander).

STF: Não se exige na linha do que penso - que o agente se aproveite especificamente do quadro de pandemia para a realização do crime, ou seja, que essa situação tenha facilitado, de alguma maneira, a ação criminosa. É suficiente, para a incidência da circunstância agravante, que o crime tenha sido cometido durante o período de calamidade pública critério temporal puramente objetivo. Orientação que acompanho nesta oportunidade, em atenção ao princípio da colegialidade (STF, Ag. Reg no RHC nº 142.585, rel. Min. Celso de Mello).

STJ - “(...) impende destacar que os autuados foram presos em flagrante durante o período de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, circunstância que eleva a reprovabilidade de suas condutas, eis que previsto como agravante genérica (art. 61, II, 'j', do CP). Veja-se que nem mesmo o alto risco de contágio foi motivo suficiente a ser ponderado pelos indiciados a fim de dissuadi-los do intento deletério de cometerem os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Não se pode olvidar também que os averiguados descumpriram orientações do Ministério da Saúde de isolamento social, o qual está sendo amplamente divulgado nos meios de comunicação. Assim, as condutas dos autuados revestem-se de maior gravidade, eis que aumentaram os índices de disseminação do vírus COVID-19 a toda população do Município, colocando em risco a saúde pública” (HC nº 584.871, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 04.06.2020, DJe 08.06.2020). TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL (...) Afastamento da agravante prevista no art. 61, II, 'j', do CP Descabimento Crime cometido durante o estado de calamidade pública decorrente do COVID-19 Inexistência legal de outros requisitos para caracterização da agravante (...) Recurso desprovido. (TJSP, Apelação Criminal nº 1510315-13.2020.8.26.0228, Rel. Camilo Léllis, 4ª Câmara de Direito Criminal, J. 16.10.2020). Com idêntico raciocínio: Apelação nº 1507788-88.2020.8.26.0228, Rel. Des. Camargo Aranha Filho, j. 21.09.2020; Apelação nº 1513982-07.2020.8.26.0228, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des.

Freitas Filho, j. 19.01.2021.

Não há atenuantes a se considerar.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a se considerar.

Fixa-se o dia-multa em seu valor unitário mínimo, em face de não haver prova da situação econômica da ré.

Diante do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva para o fim de condenar a ré com incurso nas sanções do artigo 171, "caput", do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 ano e 02 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa no valor unitário mínimo.

Os motivos que foram levados em conta para a fixação da pena favorecem a acusada e autorizam a substituição da pena privativa de liberdade uma pena restritiva de direitos, que fica ora estabelecida na pena de prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo tempo da pena substituída e por outra pena de prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo a ser destinada à entidade pública ou privada com destinação pessoal, que deverão ser determinadas no Juízo da Execução, sem o prejuízo do pagamento das diárias mínimas estabelecidas.

Em caso de eventual descumprimento, o regime inicial de cumprimento de pena é o aberto.

Considerando que a ré responde solta pelos fatos narrados nestes autos e que compareceu a todos os atos processuais, e, sobretudo, considerando a pena aplicada, não há motivos para se decretar sua prisão, já que ausentes os requisitos previstos no art. 312, do Código Penal. Assim sendo, poderá apelar desta em liberdade.

Após o trânsito em julgado, expeça-se carta de guia e oficie-se ao TRE e ao IIRGD.

Comunique-se a vítima, consoante disposição legal.

Custas na forma da lei. Deixo de isentar o réu do pagamento da referida taxa, já que não compete a este juízo esta decisão, ainda mais porque, não há os autos qualquer prova da condição econômica do réu. Neste sentido: Apelação Criminal nº 1504000-37.2018.8.26.0228, 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo).

No mais, também não se pode cogitar de redução da pena de multa, posto que foi fixada proporcionalmente à sanção carcerária, e é absurda a sua isenção, porque o preceito secundário do dispositivo legal violado prevê pena pecuniária cumulativa com a carcerária.

A propósito, eventual impossibilidade de pagamento é questão a ser sopesada não agora, mas em sede de execução criminal. (Apelação Criminal nº 1526363-47.2020.8.26.0228, da 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo).

Por fim considerando que a ré já se manifestou inúmeras vezes, no sentido de que não tem condições financeiras para arcar com a reparação dos danos sofridos pela vítima, deixo de fixá-los, devendo a parte se assim desejar ingressar com ação cível para tentar reaver seu prejuízo.

P.R.I.C.

São Paulo, 03 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA